

営利的表現の自由

海野 敦史

営利的表現の自由の意義

営利的表現の自由・序説

- ・ インターネット上において、消費者向けの電子商取引、オンライン広告（SNS広告、インフルエンサー広告等）、通信販売等の市場規模は軒並み拡大基調にあり、営利を目的とした表現（営利的表現）としての性質を帯びた表現物が流通する機会も多い。
- ・ しかし、営利的表現は、政治的表現等の「非営利的表現」とは異なり、自己統治の価値に資する度合いが概して低いと指摘されている。
⇒ 営利的表現の自由に対する表現規制（営利的表現規制）の合憲性を緩やかに捉える趨勢
- ・ 他方、営利的表現の客体となる表現物を、それ以外の表現物と規範的に区別することは、個々の表現物の価値を公権力が一方的に決めつける危険性を伴う。
- ・ 我が国では、営利的表現の自由のあり方をめぐる議論はさほど活発ではなく、判例も、一定の営利広告の禁止措置について、「公共の福祉を維持するためやむをえない措置として是認されなければならない」とするも、営利広告の自由が表現の自由の保護領域の問題かさえも明確にしていない（最大判昭和36年2月15日刑集15巻2号347頁）。
- ・ しかし、精神的活動と経済的活動との接点に立つ営利的表現に着目することは、表現の自由を支える価値や機能を再考する格好の契機に。

米国の判例にみる営利的表現の自由（Ⅰ）

ヴァージニア州薬事委員会事件判決

Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976)

- ・ 薬剤師による薬の価格の商業的宣伝を禁止するヴァージニア州の規制が修正 1 条に違反すると判示。その背景には、営利的な広告・宣伝であっても、一般的な公共の利益に資する可能性があるという思想。
- ・ 前提として、言論の自由の保障がコミュニケーション過程にも及び、言論者のみならず言論の源泉や受領者も保護されるという旨を判示。
- ・ 「営利的情報の自由な流通」に対する消費者の利益は政治的論争に対する利益に勝るとも劣らず、その流通はさまざまな経済的決定に際して不可欠となるため、ある言論が営利的な内容を主題とすることのみをもって修正 1 条の保護が及ばなくなるわけではないという旨を明言。
- ・ 営利的言論が保護される根拠として、受領者としての消費者の利益が重視され、言論者の利益が後景に退いている感。
- ・ もっとも、言論者の利益が完全に捨象されているわけではなく、その内実は純粹に経済的なものであるかもしれないが、それにより営利的言論の自由の保障が妨げられるわけではないという旨を明示。

米国の判例にみる営利的表現の自由(2)

- ・ 営利的言論に対して修正 1 条に基づく保護を付与するものとして、その後の判例にも大きな影響を与えたが、営利的言論が非営利的言論とまったく同等の保障を受けるということをも示すものではない。
- ・ 両言論の間には「常識的差異」があるというのがその理由。
- ・ かかる差異の具体的な内実として、営利的言論の真実性は政治的言論等のそれに比べて容易に検証可能であること（営利的言論の客観性）及び経済的利益を目的として行われる営利的言論は非営利的言論に比べて適切な言論規制に伴う萎縮効果の程度が低いと考えられること（営利的言論の堅牢性）が指摘。
- ・ この判決の論理によれば、営利的言論は非営利的言論よりも相対的に低い程度の保護が与えられるにとどまるということになる。
- ・ その後の判例では、営利的言論は大衆に各種の財やサービスの利用可能性、性質及び価格に関する情報を提供することで、資源配分上不可欠となる役割を果たしているため、適切な自己決定を行ううえでの各人及び社会全体の利益に資するという旨が判示（*Bates v. State Bar of Arizona*, 433 U.S. 350, 363 (1977)）。

米国の判例にみる営利的表現の自由(3)

オーラリック事件判決

Ohralik v. Ohio State Bar Association, 436 U.S. 447, 456 (1978)

- ・営利的言論は、その内容が真実か虚偽かにかかわらず、修正1条の価値に照らし「限定的な保護 (limited measure of protection)」しか受けないという旨を判示。
- ・営利的言論は暗黙裏に「低い価値」の言論と捉えられる傾向を助長。
- ・その背景には、「修正1条との関係においてすべての言論が同等の重要性を有しているわけではない」中で、「公共の関心事」である言論こそが「修正1条に基づく保護の核心」にあるという思想。

フリードマン事件判決

Friedman v. Rogers, 440 U.S. 1, 15-16 (1979)

※ テキサス州検眼士免許委員会の委員構成について、委員全6名のうち4名がテキサス検眼士会に所属する検眼士であることを定め、同検眼士が商業目的で商号を用いることを禁止したテキサス州検眼士免許法の規定について、専門性等を理由として合憲と認定。

- ・現に実害が発生していなくとも、一定の弊害の発生する可能性（詐欺的かつ誤解誘導的な営利的言論から各人を保護する必要性）等を理由として、営利的言論規制を行うことを容認。
- ・その根底には、営利的言論が営利的活動と結びついた「特殊な性質」を有するという思想。

米国の判例にみる営利的表現の自由(4)

セントラルハドソン事件判決

Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of New York, 447

※ ニューヨーク州公益事業委員会が、同州内の公益事業者に対し、資源不足に対する懸念を理由として、電気の利用促進を図る広告を中止する命令を発出し、資源不足解消後もその命令を継続したことについて、修正1条違反と認定。

- ・ 営利的言論規制が少なくとも一定の水準の合憲性審査を受けることに。
- ・ 修正1条に基づき、営利的言論は非営利的言論よりも相対的に低い程度の保護を受けることが前提とされつつ、以下の営利的言論規制に関する合憲性審査基準（**Central Hudson基準**）を提示。
 - ① 問題となる言論が非合法的又は誤解誘導的でない（ことを前提とし得る）か否か
 - ② 提示された公共の利益が実体的なものであるか否か
 - ③ 政府の措置が当該利益を直接促進するものであるか否か
 - ④ 当該措置が当該利益の促進のために必要となる範囲以上に広範となっていないか否か
- ・ Central Hudson基準は、(ア)一定の適切な態様で行われる営利的言論については修正1条に基づく相応の保護が及ぶこと、(イ)相手方を欺くことや正確な情報を与えないことを意図する営利的言論については規制されることが予定されること、を示すもの。
- ・ 言論において一般に内容規制は禁止されるが、営利的言論の場合、その客観性及び堅牢性に照らし、内容規制が許容され得るとも指摘。

米国の判例にみる営利的表現の自由(5)

ディスカバリーネットワーク事件判決

City of Cincinnati v. Discovery Network, Inc., 507 U.S. 410, 422 (1993)

- ・ Central Hudson基準の適用は、当初緩やかに解されたが、この判決を契機に厳格化される傾向に変化し、営利的言論規制の合憲性が安易に判断される場合は減少。営利的言論が「低い価値」の言論であるがゆえに広範な規制を受けるという考え方を明確に否定。
- ・ 「商取引上の弊害の防止に対する利益」こそが、営利的言論が非営利的言論よりもより広範な規制に服する典型的な理由となると判示。

44リッカーマート事件判決

44 Liquormart Inc. v. Rhode Island, 517 U.S. 484 (1996)

※ アルコール飲料の小売価格に関する広告を原則として禁止するロードアイランド州の規制について、修正1条違反と認定。

- ・ あらゆる営利的言論規制が一律的に同一の合憲性審査に服するわけではなく、真実で誤解誘導的ではない営利的言論が公正な取引過程の保護と無関係の理由により全面的に禁止される際には、修正1条が要求する厳格な審査を免れるわけではないという旨を判示。

⇒ 言論規制は非言論の行為に対する規制とは区別される中で、営利的言論規制（広告規制）はそれ以外の経済活動に対する規制よりも強い影響力を有し、その分より慎重にその合憲性が検討されなければならないという思想。

米国の判例にみる営利的表現の自由(6)

ソレル事件判決

Sorrell v. IMS Health Inc., 564 U.S. 552 (2011)

※ 患者への薬の処方に関するデータを医師の同意なしにデータ解析会社に対してマーケティング用に販売又は使用することを制限したヴァーモント州法を違憲としたもの。

- ・ 営利的言論規制は消費者を「商取引上の弊害」から保護するものでなければならないということを明示。
 - ・ 営利的言論規制に関して、それを正当化するCentral Hudson基準の充足のためには、その公共の利益が被制約利益と比例的であるだけでなく、制約を受ける言論を抑圧するものではないことが確保されなければならないという旨を明確化。
 - ・ 言論内容規制の合憲性が厳格に審査されることに関して、営利的言論もその例外となるものではないと判示。
- ⇒ 学説上、営利的言論がCentral Hudson基準に基づく保護よりも強固に保護されるということを示すもののとの評価。

米国の学説にみる営利的表現の自由（Ⅰ）

営利的言論区別説

- ・ 営利的言論の自由が保護される程度については、非営利的言論の自由のそれに比べてやや弱いと解する見解。
- ・ その主な理由として、営利企業が営利的言論たる情報にアクセスし、その真実性を確認することは容易（対抗言論による真実の開示にさらされやすい）との指摘。
- ・ また、経済的利益を目的として行われる営利的言論は（一般的な）非営利的言論に比べて、適切な言論規制に伴う萎縮効果の程度が低いとされる。
- ・ 修正 1 条の保護法益の核心は政治的言論の保護にあると捉える立場からは、個々の商品・役務との関連性が深い営利的言論は、修正 1 条の「周縁」にあるか、又は同条によっては保護されないという考え方。
- ・ さらに、言論の自由を民主政の実現の手段と捉えつつ、営利的言論は私的な利益に基づく言論にすぎず、受領者の理性に訴えかけるものでもないため、「低い価値」しか有しない（修正 1 条に基づく保護の水準も低くなる）という旨の考え方。

米国の学説にみる営利的表現の自由(2)

- ・ 営利的言論は一般に言論者の経済的利益の増大を指向するもので、自己統治の過程への参画に必要となるわけではないため、修正1条に基づき保護する価値が乏しいという旨の考え方。
- ・ 自己実現の価値を重視しつつ、少なくとも営利企業の言論は、個人の自由の行使に基づいて行われるものとは言えないため、修正1条に基づき保護されるに値しないという旨の考え方。

⇒ その場合、企業による営利的言論の自由が許容されるのは、それが個人（自然人）の言動の目的に適合する場合に限られることになり得る（営利的言論規制は多くの場合において許容され得るという帰結が導かれ得る）。
- ・ 営利的言論の保護は、その言論者となる企業の反対株主に対して当該言論に強制的に賛同させる（当該株主の言論を実質的に抑圧する）ことに結びつくことから、必要性が乏しいという考え方。
- ・ 思想の自由市場においては「アイディア」のやり取りが予定されるところ、営利的言論は一般に「アイディア」としての要素を欠いているため、修正1条に基づく保護に値しないことになるという考え方。

米国の学説にみる営利的表現の自由(3)

営利的言論非区別説

- ・ 修正 1 条に基づく保護との関係において、営利的言論を非営利的言論と規範的に区別することに對して懐疑的な見解。
- ・ 言論の内実として、政治的な重要性を有する公的な事項と消費者向けの商品・役務に関する営利的な事項とを明確に区別するのはほぼ不可能であるという旨の考え方。
- ・ たとえ政治的言論と営利的言論とが明確に区別可能であるとしても、政治的言論が公的な自己統治を推進するのと同様に、営利的言論は私的な自己統治を促進し、いずれも自己実現や自己決定との関係においてはほぼ同等の規範的な意義を有するため、両言論の保護の程度を一律に区別するのは誤りであるとする考え方。
- ・ 言論の重要性は思想の自由市場における情報の提供にあるのであって、その情報の源泉がどこにあるかということは問題とならないことから、営利的言論も非営利的言論と同様に保護されることとなるという旨の考え方。
- ・ 修正 1 条との関係における営利的言論規制の危険性（特定の利益集団の利益確保、政府の判資本主義的な偏見等）から、営利的言論にも相応の保護が求められるという旨の考え方。

憲法上の営利的表現の自由の保障(Ⅰ)

営利的表現区別説(多数説)

- ・ 営利的表現とは、さしずめ、「営業主体がもっぱらその取り扱う商品又は役務に関して営利を目的として行う事実の伝達その他の表現であって、その内容及び文脈の大半が商業的性質を帯びていると認められるもの」。
- ・ 営利的表現の自由の保障の程度は、一般に「非営利的言論のそれよりも若干弱い」とか、「より大きな制約を加えることが可能である」などと説く考え方。
 - ⇒ その根底には、営利的表現が商品や役務の取引を促す中で、それに伴う経済的・社会的な弊害を制度的に防止するのは公権力の役割となるところ、営利的表現に対して必要最小限度の規制しか認めないのは不合理であるという常識的な感覚。
- ・ その主な理由として、営利的表現の特徴に関して、以下の指摘。
 - ① 自己統治に資する度合いの低さ
 - ② 国民の健康や日常生活に影響する度合いの高さ
 - ③ 営利的表現の真実性は政治的表現等に比較して容易に検証可能であること(客観性)
 - ④ 適切な表現規制に伴う萎縮効果の程度が比較的低いこと(堅牢性)

※これに加え、営利的表現は経済的活動の一環であるとしつつ、これを表現の自由の保護領域に入るものとして捉えること自体に慎重な学説もある。

憲法上の営利的表現の自由の保障(2)

営利的表現区別説の検討

- ・「思想の自由市場」を原則的な前提としつつ、自己統治の価値及び自己実現の価値の双方が相俟って、表現の自由の保障根拠の中核を構成。
- ・前記①のような自己統治に資する度合いのみから営利的表現の保護のあり方を決することは困難。
- ・営利的表現が非営利的表現に比べて自己統治に資する度合いが低いという命題についても、疑問を挟む余地あり。
- ・前記②の国民生活への影響度合いについては、一概に営利的表現の度合いが非営利的表現の場合に比べて高いとはいいがたいし、度合いが高いとしても、そのことが営利的表現規制をただちに正当化し得ることになるわけではない。
- ・前記③のように、営利的表現の多くが真実性の証明のしやすいものであるとしても、非営利的表現との比較において常にそれがしやすいとはいえない。
- ・前記④については、営利的表現は一般に市場での緊迫した競争環境において行われることが多い中で、それが不当な表現規制により打撃（萎縮効果）を受け、営業主体の事業運営等に重大な影響が及ぶことも十分に想定される。

憲法上の営利的表現の自由の保障(3)

営利的表現非区別説

- ・ 営利的表現規制に関して「頭から緩和された審査基準が妥当すると解すべきではない」と説く学説も有力。
- ・ 営利的表現についても非営利的表現と同様の保護が妥当すると解する学説も。
- ・ 営利的表現と非営利的表現との規範的な区別自体に懐疑的な学説も。

営利的表現非区別説の検討

- ・ 確かに営利的表現規制の合憲性が当然に緩やかな審査基準で審査されるわけではないが、営利的表現の特徴を分析しないまま、非営利的表現と同様の保護と位置づけてよいのか。
- ・ 営利的表現と非営利的表現との区別は、客観的に可能であり、両者の特徴に応じて規範的な差異が認められるのであれば、それに応じた保護のあり方を追求する必要。

憲法上の営利的表現の自由の保障(4)

見解

- ・ 憲法21条1項の規定においては、「一切の表現」の自由が保障されていることから、およそ表現と認められる行為はすべてその保護領域に含まれる。
 - ・ しかし、表現物が憲法上保護される程度ないし水準については必ずしも一様ではなく、憲法上の保護法益との関係上、手厚く保護される「高い価値の表現（物）」とそれ以外の「低い価値の表現（物）」とが規範的かつ類型的に区別され得る。
- ⇒ 仮に区別されなければ、名誉毀損表現等の「低い価値」であることが通説・判例上暗黙裏に前提とされていると考えられる種類の表現にも、その自由に対する「優越的地位」が妥当し、その被害者等の基本権に関する法益が著しく害される結果となる可能性。
- ・ もっとも、公権力が個々の表現物の価値を決することには一定の危険が伴うが、各人の利益が衝突する場合の調整に際して、一定の種類の表現物を「低い価値」と捉えつつこれを特に規制することは、基本権の「最大の尊重」を図りながら適切に「公共の福祉」を確保（憲法13条）するうえで必要な行為となり得る。

憲法上の営利的表現の自由の保障(5)

- ・表現の自由の保障上、表現物の価値は、憲法の保護法益に照らして判断されることが合理的。
- ・自己統治の価値は、表現の自由が保障される結果として実現することが期待される状態であって、それ自体が表現物の価値を決める中心的な指標となるものではない。
- ・憲法の根源的な価値が憲法13条の規定に反映されていると解する支配的な学説の考え方に基づけば、その基軸は、自己統治を支える個人の尊厳及び人格的自律の保護にあると解される。
- ・それゆえ、表現物の客観的な価値についても、一次的には、個人の尊厳及び人格的自律の保護との関係を基軸として決せられるべき。
- ・これに加え、憲法上の総則的な位置づけを占める憲法14条1項の規定に基づく平等原則が、その判断に際して加味され、公権力においては、表現物が提示する見解の内容に応じて特定の表現物を差別的に取り扱ってはならないということが前提となる。
- ・したがって、表現の自由は、公的議論の過程に奉仕するか否かにかかわらず保障され、表現物の価値については、民主主義の実現に資する度合いを中心的な基準とするのではなく、自己実現の価値をも踏まえ、個人の尊厳及び人格的自律の保護に軸足をおく必要。

憲法上の営利的表現の自由の保障(6)

- ・表現行為との関係における自己実現には、表現者にとっての自己実現と受領者にとっての自己実現とがあるが、憲法21条1項の規定が一次的に保護するのは表現者の利益で、その規定に基づき予定される自己実現についても、基本的に表現者自身にとってのもの。
- ・表現者も受領者も自律的な主体である中で、仮に公権力が（自ら受領者の視点に立ちつつ）各受領者により異なり得るはずの表現物に対する評価を一方的に予見して表現規制を行えば、（表現者の自己実現のみならず）民意を通じた自己統治の確保に背馳。
- ・それゆえ、個々の表現物の価値については、一次的には、表現者にとっての個人の尊厳及び人格的自律との関係を踏まえて客観的に判断されることが合理的で、営利的表現物の場合もそれは例外ではない。
- ・他方、憲法13条後段が予定する「公共の福祉」の確保に対する要請も憲法の保護法益であり、表現物の価値の決定に際して考慮される要素。
- ・その結果、他人の基本権に関する法益を著しく害すると認められる類型の表現物については、「公共の福祉」を確保するうえで、一律的に「低い価値」と位置づけられる。
- ・以上を総合すると、表現の自由の保障の程度を決する表現物の価値は、基本的に、個人の尊厳及び人格的自律と「公共の福祉」という複合的な指標に基づき判断される。

憲法上の営利的表現の自由の保障(7)

- ・ 営利的表現は、概して以下のような非営利的表現とは異なる固有の特徴を有する。
 - ①もっぱら個々の取引における商品や役務に関する情報の表出であることが多く、その限りにおいて、営業主体自身の自律を大きく左右するものとまでは言いがたい。
 - ②営業主体が法人ないし団体であることが多く、その限りにおいて、個人の尊重の原理との関係がただちに問題となるものではない。
 - ③営業主体の営利を目的とする表出行為にほかならず、それはたとえ営業主体が自然人であっても個人の尊厳や人格的自律を体现する表現者の意思に基づく行為とは異質。
 - ④（表現の態様によっては）他の営業主体や消費者に著しい弊害をもたらす蓋然性が高く、「公共の福祉」を確保する観点からの表現規制が必要となり得る。
- ※ ここでいう「著しい弊害」とは、他の営業主体の事業運営や消費者の健康又は安全等に対して深刻な影響が及ぶと認められる場合を指す。
- ・ すべての営利的表現が常に上記特徴を常に充足するわけではないが、上記特徴が当てはまる限り、営利的表現の保護の程度は非営利的表現の場合と規範的に区別され、相対的に「低い価値」のもの（必ずしも手厚く保護されないもの）となり得る。

憲法上の営利的表現の自由の保障(8)

- ・ 以上の考察より、営利的表現については、その個人の尊厳や人格的自律との関わりが非営利的表現と比べて相対的に低いなどの特徴が認められる限りにおいて、憲法21条1項に基づく保護の程度もやや弱くなると言える。
- ・ このことは、営利的表現の自由については、常に「優越的地位」を得るわけではなく、表現の自由の保障において伝統的に説かれてきた各種の法理が必ずしも妥当するわけではないということを表す。
- ・ ゆえに、営利的表現規制が正当化される余地は、非営利的表現の場合に比べて相対的に拡大することとなる。

※なお、営利的表現が「営業」の一環を占めていると認められる場合には、その営業の自由（憲法22条1項・29条）の保護が表現の自由の保障と競合し得る。表現の自由が基本的に表現者の利益に軸足をおくのに対し、営業の自由は営業主体とその相手方としての消費者（国民各人）との双方の利益を念頭におくものと解される。営業の自由の保護法益は営業活動それ自体であり、当該活動に基づく各種の取引が、各人の国民生活及びその基盤となる個人の尊厳を支える重要なツールとなっているからである。したがって、営利的表現規制は、もっぱら営業の自由との関係に着目する限りにおいては、消費者の利益の保護の観点から比較的広範に「正当化」され得る。